

1502803-76.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas, portanto sem espaço para "iniciantes", bem como pelas informações obtidas durante a instrução, de que praticava o tráfico no local há dois dias e já foi respondeu a processo pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico (fl. 30 e consulta ao proc. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502803-76.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502803-76.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR CANDIDO BERNARDINO SOBRAL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

VICTOR CANDIDO BERNARDINO SOBRAL foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 20h57min, na rua Eucalipto, 135 - Vila Magini, nesta cidade de Mauá, o acusado, para fins de tráfico, trazia consigo e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 17-8 e laudo de constatação de fls. 14-6, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa pleiteia a nulidade da instrução por ofensa ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas, ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a menoridade relativa, a confissão e o tráfico privilegiado, sob regime penitenciário inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A preliminar suscitada pela defesa não merece acolhimento.

De partida, nota-se a ocorrência da preclusão, uma vez que nada foi requerido na resposta à acusação.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que o acordo não é direito subjetivo do réu, mas ato discricionário do Promotor de Justiça.

Mais, o pedido não encontra respaldo legal, ausente requisito objetivo. Nos termos do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal é cabível apenas nas infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o que não se aplica ao caso concreto.

Neste sentido o e. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja pena mínima é superior a 4 anos, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 584807 / SP, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 13/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENVIO DOS AUTOS AO PARQUET PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DELITO COM PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE PROPOSTA DE ANPP APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A ausência de remessa dos autos ao Parquet para oferecimento de acordo de não persecução penal não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pela Corte paulista, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. - Não obstante isso, verifica-se, de plano, o não preenchimento de um dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, porquanto apesar de o delito de tráfico de drogas ser daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele conta com uma pena mínima de 5 anos de reclusão. - Ademais, não é possível a aplicação do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal após o recebimento da denúncia, em respeito ao princípio do tempus regit actum, consignado no art. 2º do Código de Processo Penal. Desse modo, apesar de o acórdão

de apelação que confirmou a condenação do paciente, haver sido proferido em 20/3/2019, quando já estava em vigor a Lei n. 13.964/2019 (23/1/2020), a denúncia contra ele já havia sido recebida, tanto é assim, que houve sentença condenatória exarada em 20/11/2018. Precedentes. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - A expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido - 980 gramas de cocaína -, justificam a fração de redução no piso legal de 1/6, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução aludida, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. Precedentes. - Inalterado o montante da sanção (4 anos e 2 meses de reclusão), ficam mantidos o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos por imperativo legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e do art. 44, I, ambos do Código Penal. - Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 593412 / SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 23/02/2021)

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Segundo o § 1º do art. 28-A do Código de Processo Penal, para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 2. Para serem consideradas as causas de aumento e diminuição, para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), essas devem estar descritas na denúncia, que, no presente caso, inocorreu, não sendo possível considerar, no cálculo da pena mínima cominada ao crime imputado ao acusado, a causa de diminuição reconhecida apenas quando do julgamento do recurso especial. No caso do delito de tráfico, far-se-á necessário o curso da ação penal, em regra, para aferir os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que obsta a aplicação do benefício, que decorre, inclusive do tratamento constitucional e da lei que são rigorosos na repressão contra o tráfico de drogas, crime grave, que assola o país, merecendo um maior rigor estatal. 3. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, cuja causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de drogas fora reconhecida somente neste STJ, com a manutenção da condenação. 4. Embargos de declaração rejeitados.

Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Concessão de liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Pacientes que ostentam ficha criminal, sendo reincidente específico, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que são possuidores. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Incabível a aplicação, desde logo, das diretrizes firmadas pelo C. STJ, no HC coletivo 596.603, porque o reconhecimento do tráfico privilegiado depende de aprofundado cotejo de provas, compatível apenas com o juízo exauriente da sentença penal. Oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) que constitui faculdade do Parquet e é previsto na lei processual adjetiva para delitos com pena mínima inferior a 4 anos Inaplicabilidade, in casu, das medidas constantes da

Recomendação 62 do C. CNJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada." (Habeas Corpus Criminal nº 2060179-31.2021.8.26.0000, SÉRGIO COELHO, 30 de abril de 2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes - acordo de não persecução penal pena mínima maior que 4 anos - preliminares afastadas Autoria e materialidade delitiva comprovadas pena mantida regime aberto e pena privativa de liberdade substituída recurso da defesa provido em parte." (Apelação Criminal nº 1500547-97.2020.8.26.0540, ALBERTO ANDERSON FILHO, 3 de maio de 2021).

Além disso, o Enunciado 22 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União impossibilita o acordo no crime de tráfico de drogas: "veda-se o acordo de não persecução penal aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, bem como aos crimes hediondos e equiparados, pois em relação a estes o acordo não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime".

Desse modo, diante da notória posição institucional do Ministério Público de São Paulo e da ausência de requisito essencial para o oferecimento do benefício, não há prejuízo à Defesa pela não remessa ao Procurador Geral de Justiça, notadamente nos casos de réus presos.

Neste sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Isto porque, respeitando entendimento diverso, é dos autos que, não houve recusa ao oferecimento de proposta de não persecução penal e sim, a impossibilidade daquela, diante das peculiaridades do fato concreto. A decisão que indeferiu a remessa dos autos à PGJ restou muito bem fundamentada, não padecendo de qualquer irregularidade ou nulidade passível de reforma (fls. 125/126), notadamente levando-se em conta a quantidade do entorpecente apreendido (149 porções de cocaína), o que leva a crer a princípio, não se tratar de tráfico privilegiado. Cabe salientar que o acordo de não persecução penal foi recepcionado pela Lei nº 13.964/2019 e poderá ser ofertado pelo Ministério Público, discricionariamente, desde que estejam previstos os requisitos do art. 28 A do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos, posto que os pacientes não confessaram a prática delitiva, um dos requisitos autorizadores do pretendido benefício conforme se depreende dos termos de interrogatórios acostados a fls. 14/15, havendo o Parquet agido de forma irrepreensível quanto aos motivos elencados ao não formular a eles, a pretendida proposta de não persecução penal (fls. 106/109), de sorte que desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça. Cabe salientar que o Ministério Público é, antes de tudo, o defensor da ordem jurídica (artigo 127, da Constituição Federal), o fiscal da lei, numa expressão recorrente, sendo certo que o elevado ministério confiado pela Constituição Federal à Instituição é público, ou seja, traduz-se na incumbência de advogar no interesse de toda a coletividade. Nem seria preciso destacar que à sociedade interessa, tão somente, o fiel cumprimento da lei, que inclui, de um lado, o respeito ao jus puniendi estatal, nos limites estabelecidos pelas normas penais, e de outro lado, em não menor medida, a salvaguarda dos direitos e garantias individuais do acusado. Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada." (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2072332-33.2020.8.26.0000, WALTER DA SILVA, 29 de maio de 2020).

"Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes. PRELIMINAR Nulidade - Representante da acusação que deixou de ofertar acordo de não persecução penal Não preenchimento dos requisitos legais - Preliminar rejeitada. PENAS Pena-base acima do mínimo legal Atenuante de confissão espontânea não reconhecida por não ter sido integral Impossibilidade de reconhecimento das causas de diminuição de pena

prevista no art. 33, § 4º, e no art. 41, ambos da Lei nº 11.343/06 Regime inicial fechado o único adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de "sursis". PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Criminal nº 1501074-49.2020.8.26.0540, MACHADO DE ANDRADE, 14 de abril de 2021.)

"Agravamento Regimento Pedido de suspensão do andamento da persecução penal e remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça - IMPOSSIBILIDADE Carência de interesse de agir Delito de tráfico de drogas, não passível de ANPP Redação do artigo invocado suspenso (art. 28-A, §14, do CPP) Agravo não provido." (Agravo Regimento Criminal nº 2041711-53.2020.8.26.0000/50000, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, 27 de julho de 2020.)

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Postula, então, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja determinado o envio dos autos ao PGJ, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (fls. 12/13). (...) Com efeito, esta Corte possui entendimento no sentido de que "Não se pode falar na aplicação do art. 28-A do CPP ao crime de tráfico, uma vez que este não tem pena mínima inferior a 04 anos, um dos requisitos exigidos pelo referido dispositivo (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.635.787/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/5/2020). Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a" (STJ, HABEAS CORPUS Nº 602131 - SP (2020/0191853-3), MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 12 de agosto de 2020.)

Assim, o requerimento, desprovido de alguma utilidade, não pode ser acolhido.

No mérito, procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 06-9), auto de exibição e apreensão (fls. 17-8), laudo de constatação (fls. 14-6), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 92-4), laudos periciais dos objetos apreendidos (fls. 95-101) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

O réu foi devidamente interrogado, em solo policial e sob o contraditório (fl. 05 e mídia digital).

Os policiais militares, na fase administrativa, historiaram que (sic) "faziam patrulhamento pela cidade de Mauá, ocasião em diligenciaram pelo local, conhecido como de venda de drogas. Lá a avistaram o indiciado Victor Candido Bernardino Sobral, o qual ao perceber a aproximação da viatura policial apresentou comportamento furtivo, fazendo menção a correr. Fundada a suspeita, foi realizada sua abordagem. Em seu poder, no interior de uma bolsa, haviam porções de drogas diversas como cocaína, crack e maconha. De pronto, Victor afirmou que estava ali vendendo drogas há dois dias por indicação de uma amiga sobre a qual não tinha nenhuma informação. Relatou ademais que havia acabado de assumir o posto de mercancia de drogas e que ainda não havia realizado nenhuma venda. Não havia dinheiro com o indiciado, sendo os valores referentes à venda do dia levados pela pessoa que deixou o ponto para que ele assumisse" (fls 03-4).

Em juízo, os policiais militares reiteraram integralmente suas declarações. Confirmaram ter visto o acusado com uma bolsa feminina, em local conhecido pela venda de entorpecentes. Ao avisar a viatura, ele demonstrou comportamento suspeito e foi abordado. Em busca pessoal, localizaram um telefone celular. Na bolsa, apreenderam o entorpecente. Informalmente, ele admitiu a prática do tráfico no

local há dois dias (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

A quantidade de droga encontrada, incompatível com o uso, e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada e o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico, trazem elementos suficientes de que o acusado tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado 1/6 acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de drogas apreendida - 336 porções de cocaína (133,61 gramas) e 81 porções de maconha (252,46 gramas) - fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Na fase intermediária, tendo em vista a atenuante da menoridade relativa (18 anos - fl. 24), a pena retorna ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, em ponto de tráfico e em poder dos entorpecentes, não tem o

intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado

obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos-Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

Ainda assim, incidiria a Súmula 231 do STJ.

Não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

Todavia, diante das circunstâncias do delito - réu trazia consigo elevada quantidade e variedade de entorpecentes, em local conhecido como ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas, portanto sem espaço para "iniciantes", bem como pelas informações obtidas durante a instrução, de que praticava o tráfico no local há dois dias e já foi respondido a processo pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico (fl. 30 e consulta ao proc. 1501861-38.2021.8.26.0348 no ESAJ), além de não ter comprovado de forma idônea o exercício de atividade lícita - parece-me claro o acentuado envolvimento do acusado no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Evidente não se tratar de fato isolado na vida do réu.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33 § 4º da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade e nocividade da droga apreendida (um quilo de maconha). Também não há bis in idem quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na primeira fase da dosimetria da pena e, logo depois, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda" (STJ, AgRg no REsp 1690827 MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. TrattatodiDirittoProcessualePenale. v. II. Napoli: Casa EditriceDott. Eugênio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Não obstante, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado se mostra necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada.” (STF – HC 119.515/AC – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 03.12. – DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu VICTOR CANDIDO BERNARDINO SOBRAL, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 500 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego o apelo em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas, nos termos do art. 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Em relação aos objetos apreendidos, nos termos dos artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, aguarde-se eventual provocação do interessado no prazo de 90 dias do trânsito em julgado. Decorrido o prazo, sem manifestação, determino o perdimento do bem, para posterior destruição.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella – Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Maua, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA